

1500139-14.2022.8.26.0063

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARÍLIA VIZZOTTO

Comarca: Barra Bonita

Foro: Foro de Barra Bonita

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... praticar reiteradamente o delito de tráfico de drogas. No dia 24 de fevereiro de 2022, às 15h00min, na Rua Lóris Yabsek de Souza, n. 275, Jardim Altos do Igaraçu, na cidade de Igaraçu do Tietê, Comarca de Barra Bonita, os acusados, conscientes e voluntariamente, tinham em depósito, para fins de tráfico, 02 porções de crack, com peso bruto de 7,26 gramas e peso líquido de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barra Bonita

Foro de Barra Bonita

2ª Vara

Praça Dr. Meira, s/nº, Barra Bonita - SP - cep 17340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500139-14.2022.8.26.0063 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500139-14.2022.8.26.0063

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DOS SANTOS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARÍLIA VIZZOTTO

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de LUCAS DOS SANTOS e CAIQUE FERNANDO SENE DOS SANTOS, devidamente qualificados na denúncia, dados como incurso nas penas do art. 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/06, pois, em data incerta, todavia perdurando até 24 de fevereiro de 2022, na cidade de Igaraçu do Tietê, Comarca de Barra Bonita, os acusados, conscientes e voluntariamente, associaram-se para o fim de praticar reiteradamente o delito de tráfico de drogas. No dia 24 de fevereiro de 2022, às 15h00min, na Rua Lóris Yabsek de Souza, n. 275, Jardim Altos do Igaraçu, na cidade de Igaraçu do Tietê, Comarca de Barra Bonita, os acusados, conscientes e voluntariamente, tinham em depósito, para fins de tráfico, 02 porções de crack, com peso bruto de 7,26 gramas e peso líquido de 0,35 grama, sem autorização legal ou regulamentar. Consta da denúncia que investigações realizadas pela Polícia Civil de Igaraçu do Tietê apontaram que o acusado Lucas estava realizando o tráfico de drogas naquela cidade, mais especificamente na Rua Vereador Antônio Francisco, n. 5, proximidades da sede da Congregação Crista do Brasil, Jardim das Acácias. Conforme informações coligidas, Lucas era o responsável por fornecer drogas a alguns traficantes menores, que por sua vez vendiam as drogas ao usuário final. Por isso, foi

solicitada a expedição de mandado de busca e apreensão para o referido imóvel, bem como para a residência de Lucas, localizada na Rua Lóris Yabsek de Souza, n. 275, Jardim Altos do Igaraçu, o que foi deferido nos autos n. 1500118-38.2022.8.26.0063. Na residência de Lucas, foram apreendidas as 02 (duas) porções de crack supracitadas, uma tesoura com resquícios de droga, um telefone celular e a quantia em espécie de R\$ 753,00. No imóvel localizado na Rua Vereador Antônio Francisco, n.5, os policiais inicialmente constataram que se tratava da residência de Caique, pessoa com envolvimento pretérito no tráfico de drogas. Ao notar a presença dos policiais, Caique correu e se escondeu em um terreno baldio localizado nas proximidades, sendo apreendido em poder dele apenas a quantia de R\$ 60,00 em dinheiro.

Auto de prisão em flagrante delito à fl. 01.

Homologadas as prisões em flagrante, foi convertida em preventiva quanto ao réu Caique e concedida liberdade provisória, quanto ao acusado Lucas, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 85/87).

Devidamente notificados, os Réus apresentaram defesa prévia às fls. 390/392 e 412. Recebida a denúncia em 19 de julho de 2022 (fls. 413/414), foi designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual.

O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do acusado Lucas.

Na decisão de fls. 445/447 o pedido foi indeferido.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogados os Réus.

Em alegações finais, o Ministério Público e a defesa se manifestaram oralmente.

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelos termos de depoimento (fls. 02/03, 04/05 e 06), pelos termos de interrogatório (fls. 07/08, 09 e 67), pelos boletins de ocorrência (fls. 12/15 e 68/70), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 18/19), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 20/21), pelas fotografias (fls. 58 e 59/60), pela mensagem de whatsapp (fl. 63), pelos documentos (fls. 67/70), pelos laudos periciais (fls. 127/131, 132/136, 142/157, 163/173 e 174/386), bem como pela prova oral colhida em audiência.

Da mesma forma, a autoria de Lucas diante do conjunto probatório construído em sede de instrução processual, é indubitosa.

A testemunha Guilherme do Amaral Carvalho Ferrucci, em sede policial disse que é policial civil lotado nesta cidade e declarou que na data de hoje (24/02/2022), a Polícia Civil de Igaraçu do Tietê, em Operação Conjunta com a Polícia Militar, com apoio da Polícia Civil de Barra Bonita, deram fiel cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão (Processo Digital nº 1500118-38.2022.8.26.0063 da 2ª Vara de Barra Bonita/SP), na data de hoje (24/02/2022), onde foram capturados Lucas dos Santos e Caique Fernando Sene dos Santos, por suspeita da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, fatos ocorridos na Rua Lóris Yabsek de Souza, 275 - Jardim Altos do Igaraçu, na cidade de Igaraçu do Tietê - SP, onde segundo denúncias seria o local onde as drogas estariam armazenadas ("mocó"), residência de Lucas. Já na residência de Caique, na Rua Vereador Antônio Francisco nº 5C, seria a biqueira (local de venda das drogas). No momento da entrada na casa de Lucas, o mesmo estava trancado no banheiro e na cozinha, mais precisamente na porta do cômodo e próximo ao banheiro, foram encontradas duas pedras de crack, além de uma tesoura, aparentemente com resquícios de drogas. Também foi apreendido o aparelho celular de Lucas, o qual provavelmente apagou conversas enquanto trancado no banheiro e a quantia de R\$ 753,00 em notas diversas. Lucas confessou a propriedade da droga e disse que deixou cair antes de entrar ao banheiro. Lucas não possui antecedentes, mas Caique possui antecedente por tráfico de drogas. Que a Polícia Militar recebeu ainda uma denúncia por WhatsApp, provinda da câmara municipal local, onde munícipes que não quiseram se identificar teriam relatado que os moradores do local onde residem Lucas e Caique, ou seja, próximo a Congregação Cristã, estavam trancados em suas casas com medo dos traficantes que agiam na localidade. Referida denúncia foi printada e anexada a referido feito. Já o capturado Caique, que correu e tentou evadir-se para evitar a abordagem policial,

foi localizado escondido em um terreno baldio nas proximidades, onde muito provavelmente conseguiu se desfazer das demais drogas na fuga, sendo encontrado apenas na posse da quantia de R\$ 60,00 (sessenta reais) em notas diversas. Diante do cenário, apresentaram os indiciados nesta Unidade Policial para as providências legais cabíveis de Polícia Judiciária (fls. 02/03).

Ouvindo em juízo, disse que começaram a receber muitas denúncias do local, ao lado da congregação cristã, na rua antonio francisco, a casa do lucas é virando a esquina, lá é um biqueira, viu Lucas lá varias vezes. Receberam informações que lucas guardava drogas e soltava para vender. Foram feitas campanas móveis, apenas. Deferido mandado de busca, ao chegar à congregação, caíque saiu correndo e pulou um muro, sendo localizado após escondido em um terreno. Lucas estava com vários familiares na casa, disseram que ele não estava no local. Mas ao vasculhar viram que ele estava em um banheiro. Na porta do local havia 2 pedras de crack. Quando ele saiu do banheiro havia 2 pedras de crack consigo. Ele disse que era usuário de maconha e que essa pedra era para usar o mesclado. Um mês antes houve um BO de um furtador que disse que furtava para trocar na biqueira ao lado da congregação para vender para Lucas, o nome dele é Ryan Mateus Machado. Conhecia o local desde 2021. Indagados os familiares, disseram que ele já tinha trabalhado, mas estava desempregado. A casa de Lucas e caíque é bem perto, quase vizinhos. Sobre o dinheiro ele disse que havia guardado. Não foi feita extração de dados pois o celular estava com todas as mensagens apagadas. No dia da operação o carro de lucas estava quase na frente de sua casa. O nome do Caíque não havia sido mencionado, só de seu padrasto paulão, que estava trabalhando. Caíque estava na esquina de sua residência, ele estava na calçada. O irmão de caíque estava na residência.

A testemunha Juliana Soares da Silva Carvalho, em sede policial disse que é policial civil lotado nesta cidade e declarou que na data de hoje (24/02/2022), a Polícia Civil de Igarapu do Tietê, em Operação Conjunta com a Polícia Militar, com apoio da Polícia Civil de Barra Bonita, deram fiel cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão (Processo Digital nº 1500118-38.2022.8.26.0063 da 2ª Vara de Barra Bonita/SP), na data de hoje (24/02/2022), onde foram capturados Lucas dos Santos e Caique Fernando Sene dos Santos, por suspeita da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, fatos ocorridos na Rua Lóris Yabsek de Souza, 275 - Jardim Altos de Igarapu, na cidade de Igarapu do Tietê - SP, onde segundo denúncias seria o local onde as drogas estariam armazenadas ("mocó"), residência de Lucas. Já na residência de Caique, na Rua Vereador Antônio Francisco nº 5C, seria a biqueira (local de venda das drogas). No momento da entrada na casa de Lucas, o mesmo estava trancado no banheiro e na cozinha, mais precisamente na porta do cômodo e próximo ao banheiro, foram encontradas duas pedras de crack, além de uma tesoura, aparentemente com resquícios de drogas. Também foi apreendido o aparelho celular de Lucas, o qual provavelmente apagou conversas enquanto trancado no banheiro e a quantia de R\$ 753,00 em notas diversas. Lucas confessou a propriedade da droga e disse que deixou cair antes de entrar ao banheiro. Lucas não possui antecedentes, mas Caique possui antecedente por tráfico de drogas. Que a Polícia Militar recebeu ainda uma denúncia por WhatsApp, provinda da câmara municipal local, onde munícipes que não quiseram se identificar teriam relatado que os moradores do local onde residem Lucas e Caique, ou seja, próximo a Congregação Cristã, estavam trancados em suas casas com medo dos traficantes que agiam na localidade. Referida denúncia foi printada e anexada a referido feito. Já o capturado Caique, que correu e tentou evadir-se para evitar a abordagem policial, foi localizado escondido em um terreno baldio nas proximidades, onde muito provavelmente conseguiu se desfazer das demais drogas na fuga, sendo encontrado apenas na posse da quantia de R\$ 60,00 (sessenta reais) em notas diversas. Diante do cenário, apresentaram os indiciados nesta Unidade Policial para as providências legais cabíveis de Polícia Judiciária (fls. 04/05).

Ouvindo em juízo, disse que receberam denúncias anônimas a respeito de o lucas ser proprietário da biqueira que fica na frente da casa de caíque, foi até a casa de caíque mas ele correu. Quando foram a casa de lucas ele correu para o banheiro. Na residência, ao lado do banheiro encontraram 2 pedras de crack, ele assumiu a propriedade. No carro dele acharam a tesoura com resquícios de crack. O dinheiro

foi localizado por outro policial. A família de Lucas estava no local. Caique ao ver a viatura já saiu correndo, na casa do Caique, em busca, não encontraram nada. Lucas mora próximo, virando a esquina. Das campanas móveis deu para observar a movimentação de usuários passando no local. O gol de Lucas sempre fica em frente a sua casa (na casa de Lucas). Já visualizou o Lucas na biqueira.

A testemunha Marcio Roberto Assumpção da Silva, policial militar, em sede policial disse que o depoente é policial militar e dias atrás efetuou a prisão de Ryan Matheus Machado pela prática de furto de um botijão de gás e em seu interrogatório Ryan disse que havia trocado o botijão com a pessoa de Lucas, vulgo Zóio, residente na Rua Lóris Yabsek de Souza nº 275, nesta cidade. Frise-se que chegou a apreender uma pedra de crack na posse de Ryan, a qual teria sido obtida com Lucas. Consigne-se que também recaiam denúncias de que Lucas tinha relação com outras pessoas para que passava drogas para vender e uma dessas pessoas seria Caique Fernando Sene dos Santos. De posse de referidas informações a polícia civil representou pela concessão de Mandado de Busca e Apreensão, o qual foi concedido e devidamente cumprido pelas duas policiais. Ocorre que chegando pelos locais, a pessoa de Caique, ao avistar as viaturas tentou empreender fuga correndo, mas foi abordado e consigo foi encontrado a quantia de R\$ 60,00 em espécie, dinheiro que não soube esclarecer a procedências, mas provavelmente proveniente da venda de drogas. Na casa de Lucas, o mesmo estava trancado no banheiro e na cozinha foi encontrado, mais precisamente na porta do cômodo e próximo ao banheiro onde estava, duas pedras de crack semelhantes a que foram apreendida com Ryan quando de sua prisão. Foi também apreendido o aparelho celular de Lucas, o qual provavelmente apagou conversas enquanto trancado no banheiro e a quantia de R\$ 753,00 em espécie. Lucas confessou a propriedade da droga e disse que seria utilizada para fazer mesclado. Lucas não possui antecedentes, mas Caique possui antecedente por tráfico de drogas. Por fim, o depoente consigna que a Polícia Militar recebeu uma denúncia por WhatsApp, provinda da câmara municipal, onde munícipes que não se identificaram teriam relatado que os moradores do local onde mora Lucas e Caique, ou seja, próximo a Congregação, estavam trancados em sua casa com medo dos traficantes que agiam no local. Referida denúncia foi printada e anexada a referido feito (fl. 06). Ouvido em juízo, disse que começaram com um flagrante de furto em que o furtador, Ryan, disse que tinha trocado o bem na biqueira do Lucas, que é próximo à congregação crista. A PC solicitou mandado de busca e apreensão na casa de Lucas e Caique. Caique estava sentado na calçada e saiu correndo, foi alcançado há 2 quarteirões do local com 60 reais. O Lucas estava trancado no banheiro, na porta havia 2 pedras de crack e em seu bolso mais de 700 reais. Falou que ia usar o crack. Caique estava sentado entre a esquina e a residência dele. Com ele estava o seu irmão. Na casa de Caique, o irmão acompanhou as buscas e nada foi localizado. Já fez outras prisões no local, inclusive de Caique com droga e outros indivíduos. Munícipes fizeram denúncias na Câmara municipal sobre o tráfico de drogas no local. Não viu mais Lucas no local, até achou que ele estava preso ainda.

As testemunhas Gabriela, Carolina e Sirlei prestaram declarações às fls. 453-455, dizendo que Lucas é uma pessoa honesta, preocupada com a família, que trabalha e que é usuário de crack.

O Réu Lucas dos Santos, em sede policial declarou que é usuário de drogas. Que é amigo de Caique e Paulão. Que quanto aos fatos, exerce seu direito constitucional de permanecer calado e somente se manifestar em juízo. Seria inquirido nos moldes dos artigos 185 e seguintes do CPP (fls. 07/08).

Em seu interrogatório, negou a acusação, disse que as drogas eram para o seu uso. Não tinha biqueira perto da sua casa e nem trocou botijão de gás por drogas. Começou a usar crack em 2021. Os 700 reais eram do seu serviço, estava guardando dinheiro, queria comprar um celular, que o seu estava com a tela trincada. Queria juntar dinheiro para comprar um celular bom. No momento estava tomando banho e o dinheiro estava na carteira no shorts. A tesoura usava para cortar sua droga, esfarelava a droga para poder render mais para usar.

O Réu Caique Fernando Sene dos Santos, em sede policial declarou que não é usuário de drogas. Que mesmo sendo vizinho de Lucas e Paulão, afirmou desconhecer os mesmos. Quanto ao dinheiro que estava na posse afirmou ser proveniente de bicos

vendendo sorvetes. Por fim, afirmou que apenas fugiu da Polícia, pois achou que estivesse procurado ("que tava devendo") (fl. 09). Em seu interrogatório, esclareceu que a acusação não é verdadeira. Conhece o Lucas de vista, mas nunca trocou ideia com ele. Os 60 reais que tinha ganhado de sua mãe, ela recebe bolsa família. Correu da polícia pois se assustou.

Do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da LD)

Assim, diante do testemunho dos policiais e dos acusados, não resta dúvida de que a droga apreendida estava com o acusado Lucas. Isso porque, não há motivos para supor que os policiais prestaram depoimentos eivado de suspeição nem foi aventada qualquer inimizade específica com os acusados, merecendo credibilidade seu depoimento.

O depoimento de policial, como se sabe, goza de presunção de veracidade, sobretudo quando coeso com o restante da prova, não havendo qualquer circunstância a lhe desautorizar, justamente como na hipótese vertente. Presume-se a lisura do agente público, pois investido no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a uma pessoa a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Estado de São Paulo:

Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de diversas porções de entorpecentes variados - Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras - Negativa isolada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente - Redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - Bis in idem - Inexistência - Regime prisional fechado - Cabimento - Recurso da Defesa improvido com o acolhimento daquele apresentado pelo Ministério Público. (TJSP; Apelação Criminal 1500492-93.2019.8.26.0569; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 10/05/2021; Data de Registro: 10/05/2021).

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar as alegações dos acusados em detrimento da palavra do servidor público: enquanto o interesse deste é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, os daqueles é eximirem-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Mesmo o acusado Lucas, em seu interrogatório, não nega que as drogas estivessem com eles, apenas aduzindo que se tratavam de drogas para uso.

Em relação à Caíque, entendo que não há nenhum indício firme que o ligue às drogas apreendidas. O fato de estar em frente à sua residência, ainda que seja um ponto de venda de drogas (biqueira que seria de Lucas segundo depoimento policial), com R\$ 60,00 reais e ter fugido da abordagem, no sentir desse juízo, não é suficiente para autorizar a conclusão de que ele vendesse drogas para Lucas no local. Os policiais não disseram que as denúncias mencionavam o nome de Caíque e com ele nada de ilícito foi encontrado, sendo sua residência, inclusive revistada.

É importante consignar que, além da comprovação da materialidade e da autoria do fato, necessário analisar a responsabilidade criminal dos denunciados, no que se torna imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto pelo art. 52, inciso I, da Lei n. 11.343/03, que enumera as seguintes circunstâncias a serem observadas: a) natureza e quantidade da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; c) circunstâncias da prisão e; d) conduta e antecedentes do agente, a fim de que possa distinguir a aquisição de droga para uso ou para o tráfico.

No mesmo sentido, o art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06, contempla alguns parâmetros para se determinar se a droga se destinava ao uso pessoal do agente.

Destarte, dispõe o dispositivo em comento que: Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da

substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Assim, dúvidas não pairam sobre a apreensão da droga e sua titularidade, sendo certo que, nas circunstâncias em que encontradas as substâncias ilícitas e o local de apreensão, resulta indubitosa a conclusão de que não se destinavam tão somente ao uso pessoal do réu Lucas, ainda mais porque estavam acompanhadas de dinheiro (mais de 700 reais) e houve uma denúncia via aplicativo whatsapp solicitando o policiamento, no local dos fatos, pois as pessoas estavam trancadas dentro de suas residências por conta de traficantes (fl. 63).

Cabe frisar que, embora o réu tenha negado a prática do crime, sua conduta (Lucas se trancar no banheiro), a quantidade de dinheiro em notas diversas – uma vez que o réu não possui fonte de renda fixa –, e a tesoura com resquícios de droga (fls. 132/136), bem como os depoimentos das testemunhas indicam que os entorpecentes não se destinavam ao consumo pessoal, e sim à mercancia (art. 28, § 2º, da LD). Ademais, não é comum que pessoas viciadas em crack tenham consigo tamanha quantidade de dinheiro, em geral se desfazendo inclusive de bens pessoais para sustentar o vício.

Ressalto que, ainda que a quantidade de drogas apreendidas não tenha grande expressão, a intenção de mercancia ficou bem comprovada pelos depoimentos policiais e sob o crivo do contraditório. Além disso, a conduta do acusado Caíque de evitar a abordagem policial se escondendo em um terreno baldio localizado nas proximidades, bem como Lucas ter se refugiado dentro do banheiro de sua residência, indicam que eles traziam consigo drogas em quantidade superior àquelas que foram apreendidas. Friso que o réu Lucas, segundo o relato dos policiais, assumiu a propriedade das drogas, dizendo inclusive que deixou elas caírem antes de entrar no banheiro. Ademais, o policial Márcio relatou em sede policial e ratificou em juízo que, alguns dias antes da data dos fatos, efetuou a prisão de Ryan Matheus Machado pela prática de furto de um botijão de gás, e em seu interrogatório Ryan afirmou que havia trocado tal objeto com a pessoa de Lucas, "vulgo Zóio", por uma pedra de crack. Ryan disse que "(...) pegou o botijão e levou até uma "biqueira", onde passou o botijão para um rapaz conhecido por LUCAS a troco de três pedras de crack. Que já tinha consumido duas pedras, quando foi abordado pelos policiais militares que encontraram a terceira pedra de crack obtida na troca. Que sabe apenas que LUCAS mora próximo a Congregação Cristã, na rua Vereador Antonio Francisco e que o mesmo costuma comprar ou trocar objetos com ele por crack" (fl. 67). Ainda que não haja o reconhecimento de Lucas, é um forte indício que seja ele quem comercializa as drogas no local.

Por fim, ainda que não tenha transito em julgado, consigo que Lucas foi condenado pelo delito de tráfico, cujos fatos são posteriores a este, por esse mesmo juízo há poucos dias.

Dessa forma, as circunstâncias do flagrante, a quantidade das drogas apreendidas, bem como os depoimentos colhidos em juízo indicam que os entorpecentes não se destinavam ao consumo pessoal, e sim à mercancia (art. 28, § 2º, da LD), em relação apenas ao acusado Lucas.

Em relação à Caíque, por não haver prova firme que o ligue à droga aqui apreendida, entendo que deve ser absolvido por ausência de provas suficientes para sua condenação, com fulcro no art. 286, VI, CPP.

Do crime de associação para tráfico de drogas (art. 35 da LD)

O topo do art. 35 desta lei dispõe: "associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei". O tipo objetivo do art. 35 pune a associação para o tráfico (prescindindo, portanto, da concretização do tráfico), ao passo que o tipo subjetivo consiste no dolo específico de se associar, de forma permanente ou estável, para praticar tais crimes. A estabilidade e a permanência do pacto são essenciais conforme consolidado pelas decisões dos tribunais. O objeto material e jurídico é a paz pública.

No caso dos autos, não vislumbro a existência de materialidade. Não restou demonstrado pela prova produzida que haveria associação estável e duradoura, com

vinculação sólida, constituída para o fim de praticar uma série indeterminada de crimes. Outrossim, nada há nos autos que aponte, sem sombra de dúvida, a associação estável entre os acusados para o fim de traficar.

Nenhum dos depoimentos colhidos em audiência apontou que os acusados eram vistos traficando com frequência ou que tinham vinculação prévia e estável. Dessa forma, não há prova de que a traficância entre eles era estável, o que afasta a existência desse crime.

O fato de os policiais terem dito que desde 2021 conhecem o local, também não autoriza a conclusão de que esse conhecimento envolveria esses réus.

Ainda que Caíque responda outro processo por tráfico no mesmo local, isso por si só não autoriza a conclusão de que ali vendesse também neste processo, justamente, pois é sua residência. As fotos exibidas que constariam no celular de Lucas (fls. 163-386) não podem fazer prova contra si, pois não se sabe se foram remetidas a ele, se são de grupos de whatsapp ou tiradas por ele. Os policiais disseram que as denúncias, apesar de mencionar a casa de Caíque, não o mencionavam, inclusive mencionariam a pessoa de Paulo. Nesse processo, inclusive, nada de ilícito foi encontrado com Caíque.

Ainda que haja denúncias e campanhas prévias, as denúncias são abstratas, só uma delas foi juntada aos autos (fl. 63) sem menção aos réus, e sobre as campanhas, elas não foram documentadas, havendo apenas o relato de ver os réus no local, onde haviam muitos usuários (sendo que o local é ao menos vizinho à residência de ambos).

Desta forma, o Ministério Público não se desincumbiu no tocante à imputação pela associação para o tráfico, principalmente por não demonstrar o vínculo ilícito estável e permanente entre os agentes. Assim, a absolvição dos acusados pela imputação da associação, com base no art. 386, II, do CPP, é medida que se impõe. Comprovado, assim, o agir típico, em sua materialidade e autoria.

O fato imputado aos Réus também é antijurídico, vez que não restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas previstas no art. 23, CP. Eles também são maiores de 18 (dezoito) anos, penalmente responsáveis (imputável), conscientes da ilicitude dos fatos que praticaram e lhes eram exigidas condutas diversas das que exerceram. Presente, assim, a sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é medida que se impõe.

Inexistem qualificadoras ou privilégios a serem apreciados.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena.

Aplica-se ainda a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06.

Para a aplicação do referido dispositivo legal é necessário que o Réu (i) seja primário, (ii) tenha bons antecedentes, (iii) não se dedique a atividades criminosas e (iv) não integre organização criminosa.

Na espécie, o Réu é primário e de bons antecedentes (fls. 65/66), pois não possui nenhuma condenação transitada em julgado. Também não restou provado que se dedicavam a atividade criminosa ou integrava organização criminosa.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STF:

(...) A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. Conforme assentado na doutrina: "A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena". (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas . 2016. p. 50). E também: "(...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)". (GRECO FILHO, Vicente; RASSI,

João Daniel. Lei de Drogas anotada . 2009. p. 109). Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, tem a paciente o direito à redução, uma vez que se cuida de ré primária, tem bons antecedentes e não há qualquer indicação de envolvimento em efetiva organização criminosa. HC 154694 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020).

Ressalto o recente julgado do STJ, Tema n. 1139 com a seguinte tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06." Veja-se: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06. INQUÉRITO E AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 constitui direito subjetivo do Acusado, caso presentes os requisitos legais, não sendo possível obstar sua aplicação com base em considerações subjetivas do juiz. É vedado ao magistrado instituir outros requisitos além daqueles expressamente previstos em lei para a sua incidência, bem como deixar de aplicá-la se presentes os requisitos legais. 2. A tarefa do juiz, ao analisar a aplicação da referida redução da pena, consiste em verificar a presença dos requisitos legais, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração a organização criminosa. A presente discussão consiste em examinar se, na análise destes requisitos, podem ser considerados inquéritos e ações penais ainda em curso. 3. Diversamente das decisões cautelares, que se satisfazem com a afirmação de simples indícios, os comandos legais referentes à aplicação da pena exigem a afirmação peremptória de fatos, e não a mera expectativa ou suspeita de sua existência. Por isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado o emprego de inquéritos e ações penais em curso na formulação da dosimetria da pena, tendo em vista a indefinição que os caracteriza. 4. Por expressa previsão inserta no art. 5.º, inciso LVII, da Constituição Federal, a afirmação peremptória de que um fato criminoso ocorreu e é imputável a determinado autor, para fins técnico-penais, somente é possível quando houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Até que se alcance este marco processual, escolhido de maneira soberana e inequívoca pelo Constituinte originário, a culpa penal, ou seja, a responsabilidade penal do indivíduo, permanece em estado de litígio, não oferecendo a segurança necessária para ser empregada como elemento na dosimetria da pena. 5. Todos os requisitos da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 demandam uma afirmação peremptória acerca de fatos, não se prestando a existência de inquéritos e ações penais em curso a subsidiar validamente a análise de nenhum deles. 6. Para análise do requisito da primariedade, é necessário examinar a existência de prévia condenação penal com trânsito em julgado anterior ao fato, conforme a dicção do art. 63 do Código Penal. Já a análise do requisito dos bons antecedentes, embora também exija condenação penal com trânsito em julgado, abrange a situação dos indivíduos tecnicamente primários. Quanto à dedicação a atividades criminosas ou o pertencimento a organização criminosa, a existência de inquéritos e ações penais em curso indica apenas que há investigação ou acusação pendente de análise definitiva e cujo resultado é incerto, não sendo possível presumir que essa suspeita ou acusação ainda em discussão irá se confirmar, motivo pelo qual não pode obstar a aplicação da minorante. 7. Não se pode ignorar que a utilização ilegítima de inquéritos e processos sem resultado definitivo resulta em provimento de difícil reversão. No caso de posterior arquivamento, absolvição, deferimento de institutos despenalizadores, anulação, no âmbito dos referidos feitos, a Defesa teria que percorrer as instâncias do Judiciário ajuizando meios de impugnação autônomos para buscar a incidência do redutor, uma correção com sensível impacto na pena final e cujo tempo necessário à sua efetivação causaria prejuízos sobretudo àqueles mais vulneráveis. 8. A interpretação ora conferida ao art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a

atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. O que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto. 9. Não há falar em ofensa aos princípios da individualização da pena ou da igualdade material, pois o texto constitucional, ao ordenar que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, vedou que a existência de acusação pendente de análise definitiva fosse utilizada como critério de diferenciação para fins penalógicos. 10. Não se deve confundir a vedação à proteção insuficiente com uma complacência diante da atuação insuficiente dos órgãos de persecução penal. É certo que não podem ser criados obstáculos injustificáveis à atuação do Estado na defesa dos bens jurídicos cuja proteção lhe é confiada, todavia isso não legitima a dispensa do cumprimento dos ônus processuais pelos órgãos de persecução penal, não autoriza a atuação fora da legalidade e não ampara a vulneração de garantias fundamentais. Se o Estado-acusador não foi capaz de produzir provas concretas contra o Réu acerca de sua dedicação a atividades criminosas, não pode ele pretender que, ao final, esta gravosa circunstância seja presumida a partir de registros de acusações sub judice. 11. É igualmente equivocada a tentativa de se invocar uma "análise de contexto" para afastar o vício epistemológico existente na adoção de conclusões definitivas sobre fatos a partir da existência de processos sem resultado definitivo. Se outros elementos dos autos são capazes de demonstrar a dedicação a atividades criminosas, não há que se recorrer a inquéritos e ações penais em curso, portanto este argumento seria inadequado. Porém, se surge a necessidade de se invocar inquéritos e ações penais em curso na tentativa de demonstrar a dedicação criminosa, é porque os demais elementos de prova são insuficientes, sendo necessário formular a ilação de que o Acusado "não é tão inocente assim", o que não se admite em nosso ordenamento jurídico. Em síntese, a ilicitude do fundamento, que decorre do raciocínio presuntivo contra o Réu que ele encerra, não se altera em face de outros elementos dos autos. 12. Para os fins do art. 927, inciso III, c.c. o art. 1.039 e seguintes, do Código de Processo Civil, resolve-se a controvérsia repetitiva com a afirmação da tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06". A fim de manter íntegra e coerente a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 926, c.C. o art. 927, § 4.º, do Código de Processo Civil/2015, fica expressamente superada a anterior orientação jurisprudencial da Terceira Seção deste Tribunal que havia sido consolidada no ERESP n. 1.431.091/SP (DJe 01/02/2017). 13. Recurso especial provido. (Resp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Dessa forma, considerando a dinâmica dos fatos delineada na fundamentação a fração de diminuição será a de 1/2, já que o acusado Lucas, em que pese ser primário, ao ser colocado em liberdade provisória condicionada ao cumprimento das medidas cautelares previstas no art. 319, I, IV e V do CPP, no dia 15/05/2022, data posterior ao fato desses autos, foi surpreendido praticando novamente o crime de tráfico de drogas, sendo condenado como incurso no art. 33, §4º, LD, todavia não tendo a sentença transitado em julgado. Ainda que essas ações em curso não afastem peremptoriamente a aplicação do redutor, são indícios de que a intervenção estatal deve ser mais rigorosa, em especial porque o réu foi agraciado com liberdade provisória no processo mencionado e desobedecendo as condições, cometeu este delito.

Destarte, promovo a emendatio libelli, com fulcro no art. 383 do CPP, para que a capitulação do delito conste como a do art. 33, caput e §4º, da LD.

Passo à dosimetria da pena.

O réu é primário e possui bons antecedentes (fl. 65 e 66). A quantidade de drogas,

embora razoável a ponto de indicar o tráfico, não fugiu à normalidade da espécie, a quantidade em gramas líquidas, não é expressiva. Assim, considero que, para agravar a pena com base no art. 42, LD, tanto a quantidade (que no caso não é expressiva), quanto a natureza da droga, devem ser sopesadas em conjunto, nesse sentido: Básicas do tráfico elevadas apenas pela espécie da droga, apesar de pequena a quantidade e, a teor do art. 42 da Lei 11.343/06, necessário considerar ambos os fatores de forma cumulada -TJSP; Apelação Criminal 0000567-24.2018.8.26.0544; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajamar - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/11/2020; Data de Registro: 06/11/2020.

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis, de modo que lhe aplico as penas de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 61 e 65, CP). Dessa forma, fixo a pena provisória em seu mínimo legal, restando em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Conforme exposto acima, há a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06 em seu percentual de 1/2. Dessa forma, a pena definitiva é reduzida a 2 anos e 6 meses e 250 dias-multa.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90.

Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 CP, e do art. 42, Lei nº 11.343/06, o Réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime aberto.

Em face do disposto no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, e de acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que aplicou o efeito vinculante à declaração de inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" constante do citado dispositivo legal, substituo, na forma do art. 44, CP, a pena privativa de liberdade aplicada ao Réu por duas restritivas de direito, a saber: prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo em favor do Conselho da Comunidade desta Comarca, e prestação de serviços à comunidade, a ser realizada na forma do art. 46, CP - à razão de uma hora por dia de condenação, sem prejuízo à normal jornada de trabalho do Réu.

Incabível, tendo em vista a disposição contida no art. 77, III, CP.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória para:

(i) condenar o Réu LUCAS DOS SANTOS como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, convertida em penas restritivas de direitos, e 250 dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

(ii) absolver o Réu CAIQUE FERNANDO SENE DOS SANTOS como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, VI, CPP.

(iii) absolver os Réus LUCAS DOS SANTOS e CAIQUE FERNANDO SENE DOS SANTOS, já qualificados, da prática do crime previsto no art. 35, caput da Lei nº 11.343/06 (LD), com fulcro no art. 386, II, CPP.

Quanto ao Réu Lucas, desnecessária a sua prisão cautelar, posto que insuficientes os requisitos para tanto, podendo, assim, recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP).

Já quanto ao réu Caique, diante da absolvição, revogo a prisão anteriormente decretada contra o acusado, concedendo-lhe a possibilidade de, querendo, recorrer em liberdade, com fundamento nos arts. 312 e 316 do CPP.

Em razão da revogação da prisão preventiva, determino a expedição do alvará de soltura em favor do réu, se por outro motivo não estiver preso.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Com o trânsito em julgado:

a) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRG;

b) intimem-se os Réus para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para pagamento das custas processuais;

c) expeçam-se guias de recolhimento definitivo;
d) oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (art. 72 da LD);
e) como a quantia apreendida com Lucas está intrinsecamente vinculada à prática delitiva – produtos da mercancia da droga –, declaro seu perdimento em favor da União, devendo ser transferida para o FUNAD (art. 91, II, do CP); A quantia apreendida com Caíque deve ser devolvida.
f) expeça-se certidão de honorários;
g) procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça;
Condeno em custas, porém, desde já, concedo assistência judiciária gratuita por serem representados pela defensoria e diante do relatado em seus interrogatórios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumram-se as diligências necessárias e, oportunamente, arquivem-se.

Barra Bonita, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA